

1500101-77.2022.8.26.0426

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... ser reincidente específico em tráfico de drogas e já ser conhecido pelos policiais pela venda de entorpecentes; (iii) o fato de que os policiais militares à época dos fatos receberam distintas denúncias de que o acusado praticava o tráfico de entorpecentes na cidade.

Além disso, cumpre observar que, em juízo, o acusado negou a prática da traficância. Alegou que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500101-77.2022.8.26.0426 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500101-77.2022.8.26.0426

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2100308/2022 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Segundo a denúncia, no dia 12 de abril de 2022, por volta de 08h24min, na Altinópolis Julho Sales, nº. 1957, Santa Cruz, Patrocínio Paulista/SP, DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA guardava e mantinha em depósito, 10 pedras de crack, as quais totalizavam 0,01 gramas e 01 porção de maconha, que totalizava cerca de 73,9 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião da prisão em flagrante delito foi apreendida ainda em poder do denunciado diversos sacos plásticos comumente utilizados para embalar entorpecentes, tesoura, e 03 (três) aparelhos celulares. Segundo se apurou, Policiais Militares passaram a

receber diversas denúncias de que DAVID estaria praticando o tráfico de entorpecentes. Passaram e efetuar diversas diligências onde constataram a existência de movimentação atípica de pessoas na casa de DAVID, que já é conhecido nos meios policiais.

Consta, ainda, que, no dia dos fatos, os Policiais se dirigiram até a residência e, com autorização da tia de DAVID (fls. 123/131), proprietária da casa, entraram no imóvel e constataram que DAVID estava dormindo. Sobre uma pequena mesa ao lado da cama, constataram que DAVID mantinha 01 (uma) porção grande de maconha acondicionada em um saco plástico de cor preta e, ao lado de um prato e de uma lâmina de barbear, 11 (onze) porções fracionadas de crack.

Preso em flagrante em 12/04/2022, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão durante audiência de custódia conforme termo de fls. 94/97.

O denunciado foi pessoalmente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 163/168). A denúncia foi recebida (fls. 179/180) e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa e, ao final, foi interrogado o réu.

Em sede alegações finais, nos termos do art. 403, caput, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu que a imputação deveria ser julgada procedente. Ademais, retomou os elementos dos autos para embasar as alegações finais, destacando a existência de materialidade delitiva. Por conseguinte, afirmou que a autoria, da mesma forma, era certa. Reiterou os fundamentos de fls. 176 e 177 no sentido da licitude da entrada dos policiais a fim de afastar a alegação de violação de domicílio. Ressaltou a imparcialidade das condutas dos policiais e ratificou que a quantidade de entorpecentes apreendida na diligência confirmou que o acusado, efetivamente, exercia a comercialização de drogas, principalmente, ante a movimentação de usuários no local conforme acentuado pelos policiais militares. Apontou também que a quantidade de drogas e petrechos encontrados sustentam a configuração da traficância. Por fim, quanto à dosimetria, requereu a fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase, que a pena fosse agravada em razão da reincidência. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição. Apontou a impossibilidade da aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o acusado é reincidente. Por fim, quanto ao regime de cumprimento da pena, diante da reincidência específica do acusado, conforme já exposto, propôs a fixação do regime inicial fechado, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo mesmo fundamento. Já a defesa apontou que a imputação se baseia apenas nos antecedentes dos acusados. Sustentou que a tia de David não autorizou a entrada dos policiais. Quanto aos petrechos encontrados, sustentou que são objetos comuns encontrados em qualquer residência. Requereu a absolvição do acusado, bem como a desclassificação do delito de tráfico imputado na exordial para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Apontou a primariedade do acusado e requereu a fixação da pena no seu mínimo legal. É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público de São Paulo objetiva a responsabilidade criminal do réu DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA como incurso nas penas previstas para o crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há nenhuma questão preliminar a ser analisada e nem nulidade a ser declarada de ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada, em especial pelo: auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação de fls. 35/37, laudo de exame químico toxicológico de fls. 116/119, assim como pela prova oral colhida durante a instrução (mídia).

Do mesmo modo, a autoria se revelou indubitosa

Durante a instrução, a testemunha de acusação e policial militar Lucas Facuri dos Santos narrou que recebeu um disque-denúncia nominal do acusado e do local dos

fatos. Por alguns dias, aproximadamente quinze dias, efetuaram diligências e perceberam movimentações estranhas no local, seriam usuários de drogas que entravam e saíam do local. Disse que na data dos fatos, visualizou uma senhora à frente da residência e ela mesma autorizou a entrada da equipe. Dentro da residência foram encontrados os entorpecentes. Encontrou um pedaço grande de maconha, onze porções de crack e três celulares que David não soube explicar sobre sua procedência. Questionado, disse que não tinha mandado expedido, mas a tia do acusado autorizou que os policiais entrassem na residência. Disse que, por experiência, é capaz de reconhecer que seriam usuários que saíam e entravam no imóvel.

A testemunha de acusação Flavio Ferreira da Silva, policial militar, disse que receberam denúncias via disque-denúncia pelo batalhão e começaram a monitorar a região do imóvel. No dia dos fatos, em patrulha, disse que avistou uma senhora à frente da residência, ela informou que David era seu sobrinho e estava dormindo. A senhora autorizou que os policiais entrassem. Foi ao quarto do acusado e encontraram porções de crack e maconha sobre uma mesa ao lado da cama onde David estava dormindo. Afirmou que não possuíam mandado, mas a própria tia do acusado autorizou que a equipe entrasse no imóvel. Ela havia assinado o boletim de ocorrência anuindo com a entrada dos policiais.

A testemunha de defesa Marilda Aparecida dos Santos, ouvida na condição de informante, disse que estava na rua esperando a roupa para passar. Os policiais chegaram e cercaram a sua frente. Quando viu, os policiais já estavam dentro da casa. Não consentiu com a entrada dos policiais, pois eles já teriam entrado na residência. Disse que não teria como impedir a entrada dos policiais, havia cinco casas próximas umas das outras. Disse que em sua casa praticamente não havia movimentações. Nunca viu alguém procurar David, não tinha movimento em sua casa. Sabe que David é usuário há mais ou menos cinco anos. Questionada, disse que não conversou com os policiais, nem chegou a conversar com eles. David era de Franca e estava em sua casa, pois estava procurando emprego, já teria entregado diversos currículos. David morou com a declarante por uns seis meses. David ficava no quarto dos fundos, não tinha muitos amigos, ficava bastante isolado, quieto e não tinha o costume de ficar saindo toda hora, pois cuidava da filha criança. Questionada, reconhece a assinatura mostrada, mas disse que assinou no celular. Os policiais não explicaram nada, assinou o documento sem ler. Teria assinado no celular após os policiais terem pedido que ela entregasse sua identidade.

Com efeito, o acusado DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA, durante o seu interrogatório, negou o crime de tráfico disse que os entorpecentes encontrados eram para seu uso próprio. Os saquinhos plásticos eram usados para fazer "sacolés" para as crianças. A casa onde morava era de sua tia, Marilda. À época, estava trabalhando na roça em Patrocínio Paulista. Estava dormindo quando os policiais entraram. Sua tia não estava dentro da casa, ela apareceu apenas momentos depois perguntando o que estava acontecendo. Disse que a tia não estava na porta da casa, provavelmente estava na rua.

Verifico que a versão expressada em Juízo pelo acusado não encontra amparo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Dispostas as provas orais colhidas em Juízo, em que pese a negativa do acusado no sentido de alegar que as drogas seriam para seu uso pessoal, extraio dos autos que autoria delitiva imputada pelo Ministério Público foi comprovada pelos elementos de prova coligidos durante a instrução, especialmente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem e encaminhamento do acusado.

Ressalto, nesse sentido, que não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, têm o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levados em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública.

Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações ou colocar em dúvida sua imparcialidade, vez que são estes investidos pelo Estado desta função repressora.

E é este o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE

DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RESp n. 1.978.270/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/8/2022.) " Destaco que os relatos dos policiais se mostram em conformidade com os demais elementos de prova constantes nos autos, tais como auto de exibição e apreensão, laudos de constatação provisória; e exames químicos toxicológicos. Ainda, as narrativas de ambos policiais e do acusado são relevantemente harmônicas quanto aos detalhes da dinâmica do fato.

Quanto à tipicidade, dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que a adequação típica do crime de tráfico de drogas dá-se quando alguém importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, ter em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas por distintos elementos, dentre os quais: auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação de fls. 35/37, laudo de exame químico toxicológico de fls. 116/119, assim como pela prova oral colhida em juízo.

Diante disso, a autoria também é solidamente confirmada diante das declarações coincidentes dos policiais envolvidos na abordagem.

Ainda, uma vez comprovada a propriedade da droga, também restou comprovada a configuração da traficância, em especial nas modalidades "guardar" e "manter em depósito", diante de elementos sólidos, como: (i) a natureza diversa entre as drogas, que ainda se encontravam embaladas de forma individual; (ii) o fato de o acusado ser reincidente específico em tráfico de drogas e já ser conhecido pelos policiais pela venda de entorpecentes; (iii) o fato de que os policiais militares à época dos fatos receberam distintas denúncias de que o acusado praticava o tráfico de entorpecentes na cidade.

Além disso, cumpre observar que, em juízo, o acusado negou a prática da traficância. Alegou que os entorpecentes encontrados eram para seu consumo pessoal e que os petrechos também apreendidos seriam utilizados para o preparo de alimento a ser dado às crianças, seus filhos.

Todavia, referida versão não encontra respaldo nos demais elementos coligidos aos autos. Isso porque a quantidade de entorpecentes apreendida é incompatível com a alegação de sua armazenagem para uso próprio conforme alegado pelo acusado.

Foram apreendidas 10 pedras de crack, as quais totalizavam 0,01 gramas e 01 porção de maconha, que totalizava cerca de 73,9 gramas- referidas quantidades por si só, apesar de não constituírem excessiva quantidade, afastam a sustentação de que seriam todos esses entorpecentes voltados ao consumo próprio.

Além disso, as dinâmicas precedente e contemporânea da apreensão também indicam que os entorpecentes armazenados pelo acusado seriam destinados à venda ou distribuição, principalmente diante dos depoimentos dos policiais no sentido de que, durante diligências, havia movimentações estranhas no local, e que seriam usuários de drogas que entravam e saíam da residência.

Sem prejuízo, cumpre observar que não restaram evidenciados quaisquer elementos que possam ensejar eventual nulidade pautada em eventual configuração de violação ao domicílio. Isso porque, conforme a dinâmica explorada e pormenorizada tanto pelo

órgão acusatório, como também pelas testemunhas policiais em juízo, houve a regular autorização da entrada dos policiais à residência pela tia do acusado.

Provas disso são os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares ouvidos em solo judicial e também a evidência documental acostada às fls. 124/125 (também mencionada pelo policial Flavio Ferreira da Silva) que demonstra a informante Marilda Aparecida dos Santos como declarante a firmar sua declaração de que "David é seu sobrinho, não tinha conhecimento de que ele traficava em casa, colaborou com os policiais e autorizou sua entrada para verificar se havia algo de ilícito."

Ademais, há de se frisar que, conforme evidenciado pelos policiais militares em juízo, havia à época da abordagem e apreensão fundadas suspeitas de que o acusado promovia o tráfico de entorpecentes na região - em especial pelo fato de que, além de ser o local conhecido como característico ponto de tráfico de drogas, os policiais, em patrulhas reiteradas notaram movimentações estranhas que ensejaram a abordagem.

Nesse sentido afirmou o policial Lucas Facuri dos Santos que recebeu um disque-denúncia nominal do acusado e do local dos fatos. Por alguns dias, aproximadamente quinze dias, efetuaram diligências e perceberam movimentações estranhas no local, seriam usuários de drogas que entravam e saíam do local. Disse que na data dos fatos, visualizou uma senhora à frente da residência e ela mesma autorizou a entrada da equipe. Dentro da residência foram encontrados os entorpecentes. Encontrou um pedaço grande de maconha, onze porções de crack e três celulares que David não soube explicar sobre sua procedência. Questionado, disse que não tinha mandado expedido, mas a tia do acusado autorizou que os policiais entrassem na residência. Disse que, por experiência, é capaz de reconhecer que seriam usuários que saíam e entravam no imóvel.

De forma essencial, ainda é importante ressaltar que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa imputada ao acusado, a qual se restou comprovada pelo flagrante descrito.

Por conseguinte, ainda que não houvesse autorização do morador, também não se estaria diante das hipóteses de violação de domicílio diante da justa causa acima evidenciada a confirmar que, de forma subsidiária e excepcional, a entrada dos policiais à residência do acusado se deu de modo imediato e atual e fundada em razões prévias traduzidas não apenas pelas denúncias anônimas comunicadas, mas também pela constatação dos milicianos de condições suspeitas e atípicas no local.

Nesse mesmo sentido compreende o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. Nessa linha de inteligência, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria

no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora". Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)"

Ainda, em sentido semelhante:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE APONTADO COMO MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: TERCEIRO COMANDO. NULIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA: ADPF N. 635 - MC/ED DO STF. CONFISSÃO INFORMAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REVOLVIMENTO INVIÁVEL. PRECEDENTES DESTES STJ. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. PEDIDOS PREJUDICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. III - No julgamento da ADPF n. 635 - MC/ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança (...), sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação). IV - In casu, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas nas proximidades de uma igreja evangélica, localizada em área dominada pela facção criminosa denominada "Terceiro Comando". Após a tentativa de abordagem policial em via pública, o paciente e seu comparsa empreenderam fuga para uma residência próxima.(...) VIII - Inalteradas as penas impostas, prejudicados, pois, os pedidos sobre o regime inicial e a possibilidade de substituição das reprimendas. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 719.748/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)"

Ressalto ainda que os petrechos localizados (saco plástico e tesoura) também infirmam a versão exculpatória do acusado. Ademais, não há, ainda, elementos nos autos que indiquem que os policiais poderiam ter algum interesse em prejudicar o acusado imputando-lhe a prática de um crime de tamanha gravidade.

Dessa forma, a condenação do acusado se revela como medida de rigor ante o sólido acervo probatório.

Quanto aos argumentos sustentados pela d. Defesa, ressalto ser incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da referida Lei de Drogas, sobretudo diante da diversidade de natureza dos entorpecentes entre si e a forma pela qual estavam embalados, e da dinâmica de ocorrência da abordagem -especialmente em relação à existência de prévias denúncias por traficância atribuída ao réu, nos

termos já expostos nesta sentença.

Anoto, por oportuno, que, no caso vertente, também não estão presentes os requisitos legais para eventual reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.346/06, tendo em vista o fato de o acusado ser reincidente.

O tráfico de entorpecentes é crime grave e de natureza hedionda, inserido, ainda, pelo legislador na Lei nº 8.072/90. O delito ocorre em veraz crescimento e que vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado.

Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos.

É ainda considerado crime de perigo abstrato, bastando que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no tipo para configurar o delito, prescindindo, dessa forma, que o agente seja flagrado no ato de mercancia da droga propriamente dito ou que a conduta seja direcionada a uma pessoa específica.

O delito pode ser cometido pelo agente visando o lucro ou ser praticado "ainda que gratuitamente", desde que esteja praticando quaisquer das condutas "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", uma vez que, não estando preenchido este requisito, a conduta seria atípica. Assim, muito embora a expressão "tráfico de drogas" esteja relacionada ao conceito de mercancia e lucro, não há essa necessidade, bastando que o agente pratique qualquer uma das dezoito condutas descritas no artigo para sua tipificação.

A jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância.

Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP, Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

No mais, ainda que ficasse provada nestes autos, a condição de usuário não excluiria, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP, Apelação Criminal nº 1.167.864.3, rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara Criminal, j. 15.05.08). Consoante ensina Guilherme de Souza Nucci, "para a correta tipificação da conduta, é fundamental que se verifiquem os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias que envolvem a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (Leis Penais e processuais penais comentadas - 2ª ed. - Ed. RT - pág. 307).

Registre-se, por outro lado, que a simples guarda das drogas, desde que não destinadas ao consumo pessoal, já configura o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afigurando-se irrelevante perquirir se o réu já as tinha vendido ou iria vendê-las.

Por conseguinte, diante dos pontos expostos e do robusto acervo probatório contra o acusado, em que pesem as declarações testemunhais já apreciadas nesta sentença, concluo que há, nos autos, elementos firmes que confirmam a tipicidade da conduta do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas nos termos da denúncia.

Assim, ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, concluo pela responsabilidade penal do réu DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA como incurso nas penas previstas quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois restou bem configurado que sua conduta possui adequação típica, tanto em relação à materialidade, quanto à autoria.

Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Atento ao artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, verifico, com preponderância sobre o

previsto no artigo 59 do Código Penal, que a NATUREZA e a QUANTIDADE da droga apreendida, apesar de relativamente significativas, não serão valoradas negativamente; ainda com preponderância, verifico que não há nos autos elementos seguros para valorar a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL do acusado. Atento às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com CULPABILIDADE normal à espécie; possui maus ANTECEDENTES- contudo, deixo de valorar nesta fase a fim de evitar o bis in idem; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao delito; por se tratar de vago, não há que se valorar acerca do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base, em seu mínimo legal, em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa. Na segunda fase, não incidem atenuantes da pena. Contudo, incide a agravante relativa à reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), tendo em vista condenação transitada em julgado autos n. 1503123-62.2019.8.26.0196, razão pela qual agravo a pena-base acima fixada em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa. Por fim, na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Em que pese o fato de o quantum da pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b" c.c §3º, do Código Penal, diante da reincidência do réu, fixo REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ainda em razão do quantum da pena fixada ser superior a 04 anos, verifica-se que não estão presentes os requisitos contidos nos incisos do artigo 44 do Código Penal. Desse modo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do mesmo modo, em razão do quantum da pena ficada, deixo suspender a execução da pena privativa de liberdade (art. 77, caput, do Código Penal).

Estabeleço a quantia de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia multa (art. 49, § 1º, CP), vez que não há nos autos provas das condições econômicas do sentenciado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA (RG: 58.439.332- SSP/SP), como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando-o às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa fixados no patamar mínimo diário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque, uma vez presentes os requisitos legais, também permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (fls. 94/97).

Além disso, o crime em questão, além de equiparado a hediondo, é responsável por fomentar a prática de outros crimes, de inegável gravidade, a justificar a decretação da prisão preventiva com vistas a proteger a incolumidade social propriamente dita. Portanto, há necessidade de se manter a custódia do sentenciado, a fim de se evitar a reiteração na prática delitiva. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RÉU PRESO QUANDO CUMPRIA PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.

312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A decisão que impôs a prisão preventiva apontou a periculosidade do recorrente, evidenciada pelos maus antecedentes e pela



reincidência contumaz, uma vez que foi preso quando em cumprimento de pena no regime domiciliar, também pela prática de tráfico de entorpecentes. Destacou também o decreto prisional a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, indicando a intensa traficância, isso ainda aliado às informações colhidas pelo setor de inteligência da polícia militar e pelas denúncias anônimas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade delitiva reiterada.

Precedentes. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Precedentes. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Recurso desprovido. (RHC n. 129.327/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)"

De igual modo, anoto que a mera existência de qualidades subjetivas favoráveis ao sentenciado não induz, por si só, o direito de recurso em liberdade quando presentes os requisitos legais da custódia. Neste sentido: "o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva" (STJ, HC nº 339673/MG, 16/02/2016).

Nego-lhe, portanto, o recurso em liberdade.

No mais, em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar a detração no presente caso, pois não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena (prisão preventiva em 13/04/2022).

Entretanto, ainda que cumprido o lapso, não haveria elementos subjetivos que comprovassem o seu bom comportamento carcerário. Anoto que a detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Determino o perdimento da quantia apreendida.

Oficie-se ao SENAD/FUNAD e ao Banco do Brasil. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b) intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c) expeça-se guia de execução e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.
- e) Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) D. Defensor(a), cujo valor arbitro em 100 % (cem por cento) do constante da tabela OAB/DP.

Sentença registrada. Publique-se. Intime-se.

Patrocínio Paulista, 17 de agosto de 2022.